

SORAYA ARISHAH ANNE-MARIE DEGOUIS

lwn.

BADRUL HISHAM BIN SALIH

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 22 Mac 2019 bersamaan 15 Rejab 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0155-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tn. Hj. Mohd Noor Bin Bahari dari Tetuan Bahari & Bahari

Peguam Responden : Tn. Azmi Bin Tan Sri Dr. Mohd Rais dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 13/12/2018 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor di dalam kes Permohonan No. : 10400-038-0188-2018.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

(a) Bahawa suatu semakan dibuat terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara pada 15/11/2018 melalui kes Permohonan No. : 10400-038-0188-2018 sebagaimana berikut –

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003].
- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara ke atas anak yang bernama **LEA ALINA BIN BADRUL HISHAM** (No. Mykid : 150830-86-0012) diserahkan kepada Pemohon (bapa).
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut bermula jam 5.00 petang pada hari Jumaat sehingga jam 5.00 petang pada hari Ahad dengan memaklumkan kepada Pemohon terlebih dahulu. Waktu lawatan, bersama dan bermalam tersebut hendaklah dibuat bilamana Responden mempunyai kelapangan dan kehendak bagi melaksanakan hak lawatan, bersama dan bermalam tersebut.
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden sama ada dirinya atau pesuruh atau agennya atau mana-mana pihak yang mewakilinya ditegah dan / atau dihalang dan / atau diperintahkan menahan diri

daripada membawa anak tersebut keluar dari Malaysia sehingga perintah muktamad Hak Penjagaan (Hadahanah) kekal bagi anak tersebut melalui Saman No. : 10400-028-0222-2018 dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

- v. Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, badan-badan berkanun dan / atau mana-mana pihak berkuasa yang lain hendaklah memberikan kerjasama dalam melaksanakan Perintah Mahkamah ini.
 - vi. Sebarang kegagalan mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.
 - vii. Mahkamah memutuskan Perintah Interim (Ex-Parte) bertarikh 19/3/2018 dibatalkan.
- (b) Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor membatalkan keseluruhan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 15/11/2018 melalui kes Permohonan No. : 10400-038-0188-2018 tersebut ;
- (c) Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor meluluskan Permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap

keseluruhan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 15/11/2018 tersebut dan selanjutnya diubah sebagaimana berikut –

- i. Hak jagaan sementara bagi seorang anak yang bernama **LEA ALINA BIN BADRUL HISHAM** (No. Mykid : 150830-86-0012) yang berumur 2 tahun 6 bulan diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut;
- ii. Responden hendaklah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dengan serta merta dari tarikh Perintah ini diputuskan;
- iii. Responden hendaklah juga memulangkan kembali passport anak tersebut semasa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;
- iv. Responden diberi hak untuk bersama dan melawat dengan anak tersebut pada masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon;
- v. Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan / atau Jabatan Imigresen Malaysia dan / atau mana-mana agensi penguatkuasaan dan keselamatan dan / atau mana-mana agensi yang berkenaan membantu Pemohon bagi menguatkuasakan dan melaksanakan Perintah ini;
- vi. Jabatan Imigresen Malaysia hendaklah membantu Pemohon mengeluarkan nama anak tersebut daripada orang yang

disenaraihitamkan dan / atau ditegah dan / atau dihalang keluar dari Malaysia ;

vii. Kemungkiran dan / atau keingkaran dan / atau kegagalan kepada perintah ini merupakan suatu penghinaan kepada Mahkamah;

(d) Kos dan tindakan ini ditanggung oleh Responden;

(e) Lain-Lain relif yang difikirkan patut dan sesuai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 12/12/2018. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut;

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat rujukan undang-undang pada akhir perenggan 11, 12, 17-25 Alasan Penghakimannya;
- b) YA Hakim Bicara tergesa-gesa mengeluarkan Perintah Interim Ex-Parte walhal ulasan YA Hakim Bicara sendiri menyatakan tidak terdapat unsur keterdesakan dalam permohonan Responden dan tidak memenuhi kehendak seksyen 201 ETMMSS 2003.
- c) YA Hakim Bicara telah terkhilaf sama ada secara sedar atau sebaliknya dalam memutuskan dan mengeluarkan perintah sementara dengan mengekalkan sebahagian besar atau hampir keseluruhan Perintah Interim

Ex-parte sedangkan penghakimannya menolak dan membatalkan Perintah Interim Ex-Parte tersebut;

- d) YA Hakim Bicara telah khilaf dan tersalah nyata dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila dengan sewenang-wenangnya tidak mengambilkira dari segi Hukum Syarak di mana ibu adalah yang paling berhak dari segala orang yang menjaga anak kecilnya.
- e) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menekankan anak tersebut berada dengan Responden tetapi beliau tidak mengambilkira bagaimanakah anak tersebut berada di bawah jagaan Responden sejak dari Februari 2018 berbanding di bawah jagaan Pemohon sejak dilahirkan sehingga Responden membawa anak tersebut balik ke Malaysia pada 22/2/2018.
- f) YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menggunakan subseksyen 87 (3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] sebagai "*an absolute approach*" pendekatan mutlak dalam memutuskan pertukaran anak hak jagaan anak tersebut. Pendekatan YA Hakim Bicara adalah terlalu "*restrictive and limited*".
- g) YA Hakim Bicara telah terkhilaf "*fundamentally*" apabila tidak menganalisa subseksyen 87(3) EUUKIS 2003 dengan sewajarnya.
- h) YA Hakim Bicara terkhilaf dengan pendekatan sempit oleh kerana anak tersebut berada dengan Responden maka hak jagaan sementara perlu dikekalkan dengan Responden.

- i) YA Hakim Bicara tidak menyoal pihak-pihak untuk mendapatkan kepastian kedudukan dan situasi masing-masing sebelum membuat keputusan ini dan bergantung penuh pada afidavit yang difailkan tanpa memanggil deponen untuk mendapatkan kepastian.
- j) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersalah nyata apabila menyatakan *“pertukaran hak jagaan anak tersebut hendaklah dielakkan bagi mengelakkan kemudharatan kepada anak tersebut”*

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 16/8/2014 dan telah bercerai secara persetujuan bersama dengan kebenaran Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada 22/3/2018. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama **LEA ALINA BINTI BADRUL HISHAM** yang dilahirkan pada 30/8/2015 di Belgium dan mempunyai dua kerakyatan iaitu Malaysia dan Belgium.

[5] Anak tersebut telah dibawa pulang oleh Responden pada 22/2/2018 ke Malaysia atas alasan melawat keluarga Responden di Malaysia selepas dua persetujuan bersama ditandatangani oleh Pemohon dan Responden. Responden telah memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur dan juga permohonan hak jagaan sementara anak secara ex-parte di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan telah diluluskan pada 19/3/2018.

[6] Perintah Interim Hadhanah Interparte telah dikeluarkan pada 15/11/2018 setelah difailkan Afidavit Jawapan oleh Pemohon, Afidavit Balasan dan

penghujahan dari kedua-dua pihak. Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 13 Disember 2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disamak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai

Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*

- iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*

9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[9] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Kami dapati kes Permohonan No. : 10400-038-0188-2018 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara inter-parte dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun Hukum Syarak. Kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[12] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[13] Atas prinsip keadilan, pihak-pihak adalah dinasihatkan supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah Kes Saman No. : 10400-028-02222-2018 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon ~~dan fail kes yang disemak~~, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

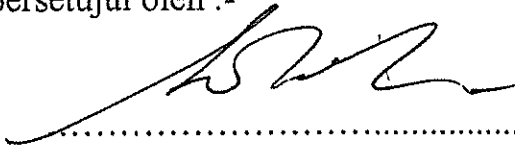
[2] Kes Saman No. : 10400-028-0222-2018 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **Y.A.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor